

las partes lleven a cabo estudios de impacto medioambiental con anterioridad al planeamiento de proyectos que puedan ocasionar un impacto transfronterizo significativo y que los notifiquen y consulten con las otras partes del Convenio.

El Ártico es una zona rica en hidrocarburos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos estimó en 2009 que la región contenía 88 billones de barriles de petróleo y 44 trillones de metros cúbicos de gas natural. Gran parte de esa reserva está localizada en aguas a menos de 500 metros de profundidad, que probablemente sean de la jurisdicción no discutida de alguno de los Estados costeros del océano Ártico<sup>51</sup>.

La Organización Marítima Internacional (OMI) se pasó años negociando un código ártico de navegación, pero solo logró en 2002 la adopción de las "Directrices para los buques que naveguen en aguas cubiertas de hielo del Ártico", que establecen siete clases de buques polares e incluyen recomendaciones para la protección de la tripulación y del medio marino<sup>52</sup>. En 2009, el Consejo Ártico publicó un informe sobre la navegación en el Ártico en el que destaca los riesgos medioambientales de esta actividad, especialmente relacionados con el derrame de petróleo, pero también relativos a lesiones ocasionadas a mamíferos marinos, la introducción de especies extrañas y los ruidos antropogénicos producidos por la navegación. El reporte insta a los Estados miembros del Consejo a trabajar conjuntamente con organizaciones internacionales, promover el desarrollo y la aplicación obligatoria de las Directrices de la OMI y armonizar sus regímenes jurídicos relativos a la seguridad en la navegación<sup>53</sup>.

Una consecuencia muy importante del calentamiento del Ártico es la repercusión en la vida de los pueblos indígenas de la zona. En 2012, la aldea de Kivalina -habitada por casi cuatrocientos pobladores Inuit y ubicada en el extremo noroeste de Alaska, Estados Unidos- demandó a un grupo de compañías de petróleo y gas -entre las que se incluían ExxonMobil, Shell y BP- reclamando la indemnización por los daños y perjuicios causados a la propiedad de la aldea por la contribución de las compañías al calentamiento global. Kivalina argumentó que las emisiones masivas de gases de efecto invernadero realizadas por estas compañías contribuyeron al calentamiento global, que ha ocasionado el derretimiento de la capa *permafrost* y, consecuentemente, la erosión de la costa de la aldea, poniéndola en un riesgo de destrucción inminente. Sin embargo, no hubo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ya que la Corte de Apelaciones del 9.º Circuito de California rechazó la demanda por falta de jurisdicción<sup>54</sup>.

A nivel internacional, en 2005, la presidenta de la Conferencia Circumpolar Inuit presentó, en representación del pueblo Inuit, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reclamando reparaciones por la afectación sufrida por el calentamiento global derivado de actos y omisiones de los Estados Unidos. Los peticionantes sostienen que Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero y que, por lo tanto, tiene la mayor responsabilidad por el calentamiento global<sup>55</sup>. Sin embargo, la Comisión Interamericana rechazó la petición porque la información brindada por los peticionantes no constituía evidencia suficiente del presunto daño ocasionado por los Estados Unidos<sup>56</sup>.

51 Byers, Michael, *op. cit.*, párr. 8.

52 *The Guidelines for Ships Operating in Arctic Ice Covered Waters*, Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional, session n.º 86 (del 27/05/2009 al 05/06/2009), disponible en <http://www.imo.org/DocStore/FNI-R0207.pdf>.

53 *Arctic Marine Shipping Assessment, 2009 Report*, Arctic Council, disponible en [http://www.arctic.noaa.gov/detect/documents/AMSA\\_2009\\_Report\\_2nd\\_print.pdf](http://www.arctic.noaa.gov/detect/documents/AMSA_2009_Report_2nd_print.pdf).

54 *Native Village of Kivalina v. ExxonMobil Corp.*, F.3d (9th Cir., 21 Sept., 2012), disponible en <http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2012/09/25/09-17490.pdf>.

55 *Ver Petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar remedio a las violaciones resultantes del calentamiento global causadas por actos y omisiones de Estados Unidos*, 2005, disponible en [http://earthjustice.org/sites/default/files/library/legal\\_docs/petition-to-the-inter-american-commission-on-human-rights-on-behalf-of-the-inuit-circumpolar-conference.pdf](http://earthjustice.org/sites/default/files/library/legal_docs/petition-to-the-inter-american-commission-on-human-rights-on-behalf-of-the-inuit-circumpolar-conference.pdf).

56 *Ver Carta de Ariel E. Dulitzky, asesor legal del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana, a Sheila Watt-Cloutier, peticionante*, 01/02/2007, disponible en [http://www.earthjustice.org/library/legal\\_docs/inter-american-commission-on-human-rights-inuit-invite.pdf](http://www.earthjustice.org/library/legal_docs/inter-american-commission-on-human-rights-inuit-invite.pdf).

### 3. El régimen jurídico de la Antártida

La Antártida fue descubierta en 1773 por el Capitán británico James Cook cuando atravesó el Círculo Polar Antártico en búsqueda de la *terra australis*. Constituye aproximadamente el 9 % del territorio terrestre y tiene una superficie de casi 14 millones de kilómetros cuadrados. Aproximadamente el 98 % del territorio está cubierto por hielo<sup>57</sup>.

La Antártida no tiene una población propia ni permanente. Se encuentra totalmente deshabitada, excepto por los científicos y militares establecidos en las bases de investigación dispuestas por algunos países, lo que la convierte en el continente más despoblado del mundo. Ello se debe, particularmente, a las condiciones extremas de su clima, en el que las temperaturas oscilan entre los 0 y los -68 grados centígrados, dependiendo de la estación.

La creciente tensión entre los Estados con intereses en la región mediante los reclamos sobre determinados sectores del continente, las divergencias surgidas en particular con relación a la explotación de los recursos y el escalamiento de la Guerra Fría tornaron imperiosa la necesidad de contar con un marco jurídico que pudiera dar certeza a la situación jurídica del continente y asegurar la armonía internacional en la región.

En ese marco histórico, el Gobierno de los Estados Unidos convocó a una serie de Estados con intereses en el continente a participar en el Año Geofísico Internacional (AGI), que se extendió desde el 1 de julio de 1957 al 31 de diciembre de 1958, ámbito en el cual se gestó el Tratado Antártico<sup>58</sup>.

El AGI fue un proyecto de cooperación entre los miembros de lo que hoy se denomina el Consejo Internacional para la Ciencia; sus actividades estaban parcialmente dedicadas a la exploración de la Antártida. Inspirados por el deseo de continuar con una pacífica cooperación científica y de evitar nuevas fricciones entre los Estados en la Antártida, Estados Unidos invitó a todos los Estados que habían participado en el AGI (Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Sudáfrica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) a formar parte de la discusión sobre el futuro del continente. Luego de varias reuniones preparatorias, la Conferencia Antártica comenzó en Washington DC el 15 de octubre de 1959 y concluyó el 1 de diciembre de 1959 con la firma del Tratado Antártico, que entró en vigor el 23 de junio de 1961.

Peterson señala que, "en virtud de ese Tratado, un continente y sus mares circundantes -que de otra manera podrían haber sido el lugar elegido para extender las disputas entre las superpotencias así como otros conflictos- fue transformado en un laboratorio no militarizado, libre de armas nucleares y de desarrollo científico conjunto"<sup>59</sup>.

#### 3.1. Los reclamos territoriales previos al Tratado Antártico

Desde su descubrimiento, siete Estados han efectuado reclamos territoriales sobre el territorio antártico (Argentina, Australia, Chile, Francia, Noruega, Nueva Zelanda y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), que cubren el 85 % del continente<sup>60</sup>. Si bien Estados Unidos y Rusia -como continuadora de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas- no han efectuado reclamo alguno, ambos Estados sostienen que tienen fundamentos legales para hacerlo. Todos estos reclamos consisten en sectores delimitados por líneas de longitud (meridianos) que convergen en el Polo Sur (a excepción del reclamo realizado por Noruega, que no llega a alcanzar el Polo). El 15 % del territorio restante no fue objeto de ningún reclamo y es el que se encuentra ubicado entre los meridianos de 90° y 150° de longitud oeste. Algunos

57 Joyner, Christopher C., "Introductory Remarks", *The United Nations and the Antarctic Treaty System, American Society of International Law Proceedings*, 9-12 de abril de 1986, p. 1.

58 Ver Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, *Antártida y el Sistema del Tratado Antártico*, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 1996, capítulo I.

59 Peterson, M. J., *Managing the Frozen South*, University of California Press, Berkeley/ Los Angeles, 1986, p. 1 (traducción libre).

60 Joyner, Christopher C., *op. cit.*, p. 1.

autores sostienen que dicho espacio no reclamado puede considerarse hoy en día un espacio común internacional<sup>61</sup>.

Los Estados fundan sus reclamos de soberanía en distintos argumentos jurídicos, entre los que se comprenden la ocupación, la contigüidad, el principio sectorial, la continuidad, la exploración, el descubrimiento y los títulos históricos. Algunos de estos argumentos no son aceptados por el derecho internacional como modos de adquisición de territorios y su validez es hartamente discutida<sup>62</sup>. Asimismo, ninguno de los reclamos territoriales ha sido reconocido por Estados no reclamantes de soberanía. En sentido contrario, los Estados reclamantes de soberanía, a excepción de los territorios pretendidos por Argentina, Chile y Reino Unido –que se yuxtaponen– reconocen los reclamos efectuados por los otros Estados. La República Argentina reclama el Sector Antártico Argentino, que queda comprendido debajo del paralelo de 60° de latitud sur y entre los meridianos de 25° y 74° de longitud oeste.

El único intento de delimitar el territorio antártico ante un tribunal internacional fue realizado por el Reino Unido en 1955, cuando presentó ante la CIJ dos casos: uno contra Argentina<sup>63</sup> y otro contra Chile<sup>64</sup>. Debido a que los Estados demandados no aceptaron la jurisdicción de la CIJ para resolver la disputa concerniente al territorio antártico, esta nunca llegó a analizar la cuestión, y los casos fueron retirados de su lista<sup>65</sup>.

Sin embargo, en la práctica, estos reclamos no juegan hoy en día un rol preponderante, puesto que, por voluntad de las partes, desde la entrada en vigor del Tratado Antártico, los reclamos de soberanía han quedado congelados por aplicación del artículo IV del Tratado, al cual nos referiremos más adelante.

### 3.2. El Sistema del Tratado Antártico (STA)

El STA enmarca todos los acuerdos realizados por los Estados para coordinar las relaciones y actividades que se suscitan en el continente antártico. Consiste, principalmente, en el Tratado Antártico, en las recomendaciones adoptadas por los Estados parte en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico (RCTA), en la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (CCFA), en la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) y en el Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, del Tratado Antártico. La Convención para la Regulación de las Actividades de los Recursos Minerales en la Antártida (1988) nunca entró en vigor y, por lo tanto, no integra el STA.

#### 3.2.1. El Tratado Antártico

Desde que el Tratado Antártico fue concluido en 1959 por los doce Estados signatarios, otros treinta y ocho Estados se adhirieron a este. En total, el Tratado vincula a cincuenta Estados parte. Como los intereses de los doce Estados negociadores eran muy diversos, el Tratado solo refleja el mínimo de consenso que se logró alcanzar en esa etapa, como resultado de una delicada negociación en un escenario político internacional sensible<sup>66</sup>. Mansi señala que la intención principal de los signatarios "consistió en alcanzar en plena Guerra Fría un entendimiento político duradero que permitiese preservar a la Antártida de la intervención militar"<sup>67</sup>.

61 Barboza, Julio, *Derecho Internacional Público*, Zavalla, Buenos Aires, 2.ª edic., 2008, p. 212; Chopra, Sudhir, "Antarctica in the United Nations: Rethinking the Problems and Prospects", *The United Nations and the Antarctic Treaty System, American Society of International Law Proceedings*, 9-12 de abril de 1988, p. 3.

62 Vónky, Sílvia y Addison-Agyei, Sange, "Antarctica" (2012), en *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, <http://www.mpepil.com>.

63 *Asunto de la Antártida* (Reino Unido c. República Argentina), Solicitudes de incoación de procedimiento, 04/04/1955.

64 *Asunto de la Antártida* (Reino Unido c. Chile), Solicitudes de incoación de procedimiento, 04/04/1955.

65 *Asunto de la Antártida* (Reino Unido c. República Argentina), CIJ, Providencia, 18/03/1958, *ICJ Reports 1958*, p. 12. *Ibid.* (Reino Unido c. Chile).

66 Molinari, Ángel E., "Notas sobre el Tratado Antártico a 50 años de su firma", en *Las Regiones Polares: Estrategias, Oportunidades y Desafíos*, Barboza, Julio; Colacrai, Miryam y otros, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Buenos Aires, 2009, p. 31.

67 Mansi, Ariel R., "Las características y el funcionamiento del régimen jurídico de la conservación de los recursos vivos marinos antárticos", en *La Argentina en la Antártida*, Molinari, Ángel Ernesto (coord.), Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Buenos Aires, 2005, p. 89.

Como ya se mencionó, el tratado fue suscripto el 1 de diciembre de 1959 y entró en vigor el 23 de junio de 1961, luego de su ratificación por los doce países signatarios.

Se encuentra debatido en la doctrina si el Tratado Antártico constituye un "régimen objetivo" y, por lo tanto, tiene efectos vinculantes *erga omnes*<sup>68</sup>. Entre quienes sostienen que se trata de este tipo de regímenes se encuentran Dupuy<sup>69</sup>, Santa Cruz<sup>70</sup>, y Guyer<sup>71</sup>. Entre los que se oponen a esta caracterización podemos mencionar a Tunkin<sup>72</sup> y Mouton<sup>73</sup>.

#### 3.2.1.1. Ámbito de aplicación personal, territorial y temporal

El Tratado Antártico aplica a toda el área ubicada debajo del paralelo de 60° de latitud sur, incluyendo todos los bloques de hielo (art. VI). La relación entre el Tratado y la CONVEMAR será analizada posteriormente, aunque se puede afirmar que el Tratado no obstruye la aplicación de la CONVEMAR, pero es controvertida la cuestión sobre la existencia de mares territoriales, zonas contiguas y económicas exclusivas y plataformas continentales en el continente antártico.

El Tratado es de duración indeterminada y solo prevé la opción de un proceso de revisión luego de treinta años de su vigencia. Este puede ser requerido por cualquiera de los miembros consultivos<sup>74</sup>. Antes de cumplirse ese plazo, únicamente estaba prevista su modificación por decisión unánime de los miembros consultivos. El Tratado tampoco prevé que un Estado pueda retirarse de él en cualquier momento, sino que solo contempla la posibilidad de que un Estado contratante deje de ser parte en caso de enmienda del Tratado, como se analizará infra.

Dado que es un tratado abierto, cualquier miembro de las Naciones Unidas o cualquier Estado que sea invitado por los Estados contratantes puede adherirse a él<sup>75</sup>. El Estado que se obligue por el Tratado lo estará también por todas las recomendaciones adoptadas por el RCTA. Para llegar a ser una parte consultiva será también necesario obligarse por el Protocolo sobre el Medioambiente, de conformidad con el artículo 22(4) de este.

#### 3.2.1.2. Los lineamientos generales del Tratado Antártico

El Tratado está basado en cuatro objetivos principales: la utilización de la Antártida para fines exclusivamente pacíficos, la libertad de investigación científica, la protección del medioambiente antártico y el congelamiento de los reclamos territoriales<sup>76</sup>.

Los primeros dos principios están reconocidos en el preámbulo y en los primeros dos artículos del Tratado. El artículo I prohíbe toda medida de carácter militar, aunque la presencia de personal militar o equipamiento está autorizada para su uso científico. La libertad de investigación científica está regulada en los artículos II y III del Tratado. Con el fin de promover la cooperación, las partes acordaron proceder al intercambio de información sobre los proyectos científicos, de personal científico entre las expediciones y de observaciones y resultados relativos a las investigaciones<sup>77</sup>. Para dar cumplimiento a tales obligaciones, cada Estado elabora anualmente un informe oficial que hace circular a los demás Estados parte, en virtud de estándares científicos previamente consensuados.

68 Simma, Bruno, "The Antarctic Treaty as a Treaty Providing for an Objective Regime", *Cornell International Law Journal*, vol. 19 (1988), p. 189. Gutierrez Posse sostiene que el sistema del Tratado Antártico en interés de toda la humanidad "ha generado –en lo sustancial– un régimen objetivo oponible *erga omnes*"; Ver Gutierrez Posse, Hortensia, "Los tratados que establecen un régimen objetivo y la Antártida", en *Antártida al milenio la década de 1990*, op. cit., p. 49.

69 Dupuy, Pierre, "Le Traité sur l'Antarctique", *Annuaire Française de Droit International*, vol. 6 (1960), p. 111.

70 Santa Cruz, Fernando, "The Antarctic System and the Utilizations of Resources", *University of Miami Law Review*, vol. 33 (1978), p. 439.

71 Guyer, Roberto, "The Antarctic System", *R.C.A.D.I.*, vol. 138 (1978), pp. 228-226.

72 Tunkin, Grigory, Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, vol. 1, UN Doc. A/CN.4/SER.A/1984.

73 Mouton, Jean Denis, "The International Regime of the Polar Regions", *R.C.A.D.I.*, vol. 107 (1962), pp. 257-259.

74 Tratado Antártico, artículo XII.

75 *Ibid.*, artículo XIII.

76 Vónky, Sílvia y Addison-Agyei, Sange, op. cit.

77 Tratado Antártico, artículo III.

El preámbulo del Tratado Antártico reconoce "que es en interés de toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional". Esta referencia al "interés de toda la humanidad" ha sido objeto de interpretación por la doctrina. Vinuesa aclara que "no es la utilización pacífica 'el interés de la humanidad' sino la voluntad de los Estados Parte respecto de lo que ellos consideran que es 'en interés de la humanidad'"<sup>78</sup>. Por su parte, Armas Barea enfatiza que la noción de interés de la humanidad —que se aplica en el contexto de la Antártida— no debe confundirse con la de "patrimonio común de la humanidad"—concepto que surgió con posterioridad a la conclusión del Tratado Antártico— y explica las razones por las cuales este último concepto no es aplicable a esta región<sup>79</sup>. Ello se debe a que no han faltado ocasiones en las que se haya vinculado dicha noción con la situación de la Antártida<sup>80</sup>.

La protección del medio ambiente antártico no está expresamente mencionada como un objetivo del Tratado Antártico. Este solo prohíbe las explosiones nucleares y el desecho de material radioactivo. Sin embargo, los miembros consultivos han hecho de la protección ambiental un tema central desde un principio y muchos pasos importantes se han tomado en ese sentido. Dos recomendaciones en particular se han acordado con tal fin: la Recomendación III-VIII para la Conservación de la Fauna y la Flora Antártica y la Recomendación VIII-11, que establece el Código de Conducta para las Expediciones y las Actividades<sup>81</sup>.

El Tratado regula la cuestión de la soberanía territorial en el artículo IV, que ha sido descrito "como la piedra fundamental del Tratado Antártico"<sup>82</sup>. Este establece lo siguiente:

1. Ninguna disposición del presente Tratado se interpretará: (a) como una renuncia, por cualquiera de las Partes contratantes, a sus derechos de soberanía territorial o a las reclamaciones territoriales en la Antártida, que hubiere hecho valer precedentemente; (b) como una renuncia o menoscabo, por cualquiera de las Partes Contratantes, a cualquier fundamento de reclamación de soberanía territorial en la Antártida que pudiera tener, ya sea como resultado de sus actividades o de las de sus nacionales en la Antártida, o por cualquier otro motivo; (c) como perjudicial a cualquiera de las Partes Contratantes, en lo concerniente a su reconocimiento o no reconocimiento del derecho de soberanía territorial, de una reclamación o de un fundamento de reclamación de soberanía territorial de cualquier Estado en la Antártida. 2. Ningún acto o actividad que se lleve a cabo mientras el presente Tratado se halle en vigencia constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclamación de soberanía territorial en la Antártida, ni para crear derechos de soberanía en esta región. No se harán nuevas reclamaciones anteriormente hechas valer, mientras el presente Tratado se halle en vigencia.

Esta disposición, que suele ser llamada "cláusula paraguas", congela los reclamos y los fundamentos territoriales existentes al momento de la celebración del Tratado Antártico. Es una solución que reconoce a los Estados que han efectuado reclamos territoriales sobre la Antártida pero, asimismo, sienta un principio muy importante, el cual determina que ninguna de las actividades que se conduzcan en la Antártida por aplicación de las normas establecidas en el Tratado puede ser considerada a los fines de realizar una ulterior reclamación territorial. Finalmente, establece que no se podrán ampliar los reclamos territoriales existentes ni podrán efectuarse nuevos reclamos. La situación jurídica determinada por esta cláusula es única en

78 Vinuesa, Raúl, "El Sistema Antártico: Propósitos y principios", en *Antártida al iniciarse la década de 1990*, Armas Barea, Calixto y Beltramo, Juan Carlos (eds.), Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 1992, p. 14.

79 Armas Barea, Calixto, "Los conceptos de 'Interés de la Humanidad' y 'Patrimonio Común de la Humanidad'", en *Antártida al iniciarse la década de 1990*, op. cit., pp. 23, 32-33.

80 Ver Nascimbene de Dumont, Norma, "El Sistema del Tratado Antártico y las Naciones Unidas", en *Antártida al iniciarse la década de 1990*, op. cit., pp. 57-58; Cullen, Domingo, "Perspectivas de la 'Cuestión de la Antártida' en las Naciones Unidas", en *Antártida al iniciarse la década de 1990*, op. cit., pp. 63-64.

81 Voneky, Silja y Addison-Agyei, Sange, op. cit.

82 Trolle-Anderson, Rolf, "The Antarctic scene: Legal and Political Facts", en *The Antarctic Treaty Regime*, Triggs, Gillian (ed.), Cambridge University Press, Cambridge, 1987, p. 59 (traducción libre).

el mundo. El régimen jurídico que establece el artículo IV del Tratado hace que la Antártida no sea un espacio común fuera de toda jurisdicción nacional ni tampoco que se encuentre bajo la soberanía de ningún Estado en particular. Algunos países en desarrollo y las Naciones Unidas han manifestado que la Antártida es el tipo de territorio que no podría ser objeto de reclamación alguna por ningún Estado.

Al respecto, Moncayo sostiene:

El Tratado no define ni resuelve controversia territorial alguna, no consigna los derechos de los Estados territorialistas o los de aquellos que poseen un fundamento de reclamación de soberanía territorial, pero tampoco consagra su declinación. Si no afirma derechos territoriales, no los desconoce. Tampoco internacionaliza la Antártida<sup>83</sup>.

La existencia de un mar territorial, una zona contigua y una zona económica exclusiva y, asimismo, de una plataforma continental en la Antártida es altamente debatida. Esto implica cuestionar si las previsiones de la CONVEMAR resultan aplicables al régimen jurídico implementado por el Tratado Antártico, lo que será abordado más abajo.

Al ratificar la Convención para la Conservación de las Focas Marinas Antárticas, la República Argentina formuló la siguiente declaración:

La República Argentina deja constancia de que la mención del artículo IV del Tratado Antártico contenida en el artículo I de la 'Convención para la "Conservación de Focas Antárticas"' significa que nada de lo establecido en dicha Convención afecta o menoscaba sus derechos de soberanía y jurisdicción marítima y su posición jurídica en esta materia<sup>84</sup>.

La Unión Soviética objetó justamente por considerarla en conflicto con el artículo IV(2) del Tratado Antártico<sup>85</sup>.

### 3.2.1.3. Categorías de Estados contratantes

El Tratado diferencia entre tres tipos de miembros: en primer lugar, los doce Estados signatarios; en segundo lugar, los Estados adherentes que demuestren interés en la Antártida llevando a cabo proyectos importantes de investigación científica; y finalmente, otros Estados adherentes<sup>86</sup>. Los Estados contratantes que integran las primeras dos categorías mencionadas son llamados "miembros consultivos" y poseen voz y voto en las reuniones consultivas. Para pertenecer a este selecto grupo, es requisito *sine qua non* el desarrollo de la actividad científica y el establecimiento de una base para desarrollar tales tareas<sup>87</sup>.

El proceso de toma de decisiones implementado tiene lugar a partir de las decisiones adoptadas en el marco de las RCTA. Hasta 1983, en las RCTA solo podían participar los miembros consultivos. A partir de ese año, se permitió la participación de todos los Estados contratantes, aunque reservando el voto exclusivamente a los miembros consultivos. En 1987, se permitió incluso la participación de Estados observadores y de expertos de distintas organizaciones internacionales, estos últimos sujetos a invitación.

Las partes acordaron que la primera reunión consultiva fuera llevada a cabo en Cambera, Australia, a los dos meses de entrar en vigor<sup>88</sup>. Esta primera reunión tuvo lugar el 10 de julio de 1961. A partir de ese encuentro y hasta 1994, las RCTA se llevaron a cabo cada dos

83 Moncayo, Guillermo, "Antártida: Condición de los Estados territorialistas", en *Antártida al iniciarse la década de 1990*, op. cit., p. 39.

84 El texto se reproduce en la Ley 21.676 (B.O. 04/11/1977), aprobatoria de la Convención en la República Argentina.

85 Moncayo, Guillermo, op. cit., pp. 41-42.

86 Tratado Antártico, artículo IX.

87 Rothwell, Donald, "Polar Lessons for the Arctic Regime", *Cooperation & Conflict*, vol. 29, n.º 1, 1994, p. 57.

88 Tratado Antártico, artículo IX.

años. Debido a la complejidad de la temática relativa a la Antártida, en 1994 se decidió que esas reuniones fueran celebradas anualmente.

De conformidad con el artículo IX del Tratado Antártico, los Estados pueden adoptar medidas, las cuales resultan vinculantes cuando se aprueban por la totalidad de los miembros consultivos. Estas eran conocidas con el nombre de "recomendaciones". A partir de 1995, se hizo una diferenciación entre tres tipos de decisiones que se pueden adoptar en el marco del Tratado: medidas, decisiones y resoluciones. Solo las primeras son vinculantes para todos los Estados contratantes y requieren la aceptación de todos los miembros consultivos. En sentido contrario, las decisiones, que abordan asuntos organizativos internos de las RCTA, y las resoluciones, que son textos exhortatorios, no son jurídicamente vinculantes para los Estados contratantes.

Este procedimiento de toma de decisiones por vía del consenso entre los miembros consultivos traduce a la práctica el principio de igualdad soberana de los Estados, le otorga a cada uno la posibilidad de participar en la adopción de decisiones y lo legitima a bloquear cualquier resolución que sea contraria a sus intereses<sup>89</sup>.

#### 3.2.1.4. Jurisdicción y solución de controversias

La única cuestión relativa a la jurisdicción que se aborda en el Tratado Antártico es la que concierne al personal científico y su equipo que hubieran sido designados por alguno de los Estados, adoptándose el criterio de nacionalidad. Toda disputa concerniente a cuestiones de jurisdicción deberá ser resuelta mediante consultas amistosas<sup>90</sup>.

Con relación a las controversias que pudieran suscitarse con motivo de la interpretación o la aplicación del Tratado, se prevé la consulta, el arbitraje, la decisión judicial u otros medios de solución pacífica de controversias que sean elegidos. En el caso de que la controversia no pueda ser resuelta a través de los métodos intentados, se prevé la remisión de la cuestión a la CIJ, previo consentimiento de los Estados involucrados<sup>91</sup>.

#### 3.2.1.5. Enmienda y revisión del Tratado Antártico

El artículo XII del Tratado regula el supuesto de que sea objeto de una modificación o enmienda. Sin embargo, cabe aclarar que el término modificación no es empleado con el mismo sentido que lo hace el artículo 41 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969). El Tratado Antártico no se refiere a la modificación como un acuerdo colateral que celebran algunas de las partes del Tratado para modificarlo en sus relaciones mutuas, sino que emplea ese término como sinónimo de enmienda, probablemente para aludir a un cambio o modificación parcial. En efecto, el artículo XII del Tratado Antártico dispone:

1. a) El presente Tratado podrá ser modificado o enmendado, en cualquier momento, con el consentimiento unánime de las Partes Contratantes, cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones previstas en el artículo 9. Tal modificación o tal enmienda entrará en vigencia cuando el gobierno depositario haya sido notificado por la totalidad de dichas Partes Contratantes de que las han ratificado.

b) Subsiguientemente, tal modificación o tal enmienda entrará en vigencia, para cualquier otra Parte Contratante, cuando el gobierno depositario haya recibido aviso de su ratificación. Si no recibe aviso de ratificación de dicha Parte Contratante dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la modificación o enmienda, en conformidad con lo dispuesto en el subpárrafo 1 a) de este artículo, se la considerará como habiendo dejado de ser Parte del presente Tratado en la fecha de vencimiento de tal plazo.

2. a) Si después de expirados treinta años, contados desde la fecha de entrada en vigencia del presente Tratado, cualquiera de las Partes Contratantes, cuyos represen-

89 Mollinari, Angel, *op. cit.*, pp. 33-34.

90 Tratado Antártico, artículo VIII(2).

91 *Ibid.*, artículo XI.

tantes estén facultados a participar en las reuniones previstas en el artículo 9, así lo solicita, mediante una comunicación dirigida al gobierno depositario, se celebrará, en el menor plazo posible, una Conferencia de todas las Partes Contratantes para revisar el funcionamiento del presente Tratado.

b) Toda modificación o toda enmienda al presente Tratado, aprobada en tal Conferencia por la mayoría de las Partes Contratantes en ella representadas, incluyendo la mayoría de aquellas cuyos representantes están facultados a participar en las reuniones previstas en el artículo 9, se comunicará a todas las Partes Contratantes por el gobierno depositario, inmediatamente después de finalizar la Conferencia, y entrará en vigencia de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

c) Si tal modificación o tal enmienda no hubiere entrado en vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el subpárrafo 1 a) de este artículo, dentro de un período de dos años, contados desde la fecha de su comunicación a todas las Partes Contratantes, cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en cualquier momento, después de la expiración de dicho plazo, informar al gobierno depositario que ha dejado de ser Parte del presente Tratado, y dicho retiro tendrá efecto dos años después que el gobierno depositario haya recibido esta notificación.

Como puede observarse, en el inciso 1 se prevé la posibilidad de que el Tratado sea enmendado "en cualquier momento" (es decir, tanto antes -cosa que no ocurrió- como después de los treinta años de vigencia) con el consentimiento unánime de los miembros consultivos. En tal supuesto, la enmienda entrará en vigor en general recién cuando todos los miembros consultivos la ratifiquen. Esta misma enmienda va a entrar en vigor para cada uno de los demás Estados contratantes -es decir, los "no consultivos" - cuando cada uno de ellos la ratifique. Sin embargo, como este Tratado no permite dualidad de regímenes -es decir que el Tratado rija con enmienda para algunos Estados y sin enmienda para otros-, prescribe que los Estados contratantes (no consultivos) que no lo ratifiquen dentro del plazo de dos años de la entrada en vigor en general de la enmienda dejarán de ser parte del Tratado.

A partir de los treinta años de entrada en vigor del Tratado (lo que ocurrió en 2001), se prevé la revisión del funcionamiento del Tratado en una conferencia a celebrarse a pedido de cualquiera de los miembros consultivos. En dicha conferencia, la enmienda podrá ser aprobada por mayoría de los Estados contratantes, incluyendo la mayoría de los miembros consultivos. Es decir, se trata de una mayoría calificada. Sin embargo, para que esta enmienda entre en vigor se requiere también de la ratificación unánime de los miembros consultivos. Para el supuesto de que la enmienda no llegue a entrar en vigor dentro de un período de dos años, cualquier Estado contratante podrá retirarse en cualquier momento posterior y dejar de ser parte del Tratado (retiro que tendrá efecto dos años después de que notifique al depositario esta decisión).

En consecuencia, la única posibilidad de retiro de un Estado contratante que contempla este Tratado es como consecuencia de un proceso de enmienda.

Hasta el presente, el Tratado no ha sido modificado o enmendado y tampoco se ha convocado una conferencia de revisión.

#### 3.2.1.6. La Secretaría del Tratado Antártico

El Tratado Antártico no prevé ninguna institución permanente u oficinas centrales. La labor administrativa que debía ser llevada a cabo para el cumplimiento de los objetivos impuestos por el Tratado era asumida por los Estados anfitriones de las RCTA.

Con el paso del tiempo, se hizo patente la necesidad de contar con una institución permanente. Luego de extensas deliberaciones, se decidió la creación de una Secretaría, con sede en Buenos Aires<sup>92</sup>. Esta comenzó a funcionar el 1 de septiembre de 2004 y se encuentra a cargo de un secretario ejecutivo, cuya nacionalidad debe ser de uno de los Estados contratantes.

92 Decisión del RCTA XXIV-1; Medida del RCTA XXVI-1.

Las funciones de la Secretaría del Tratado, que son de naturaleza administrativa, están establecidas en el artículo 2 de la medida xxvi-1 de la RCTA. La Secretaría posee personalidad jurídica dentro del ordenamiento argentino, y los privilegios e inmunidades de los que gozan sus miembros están establecidos en el Acuerdo de Sede para la Secretaría del Tratado Antártico.

### 3.2.2. El Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente (PPMA)

El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente fue firmado en Madrid, España, el 4 de octubre de 1991 y entró en vigor el 14 de enero de 1998. Complementa al Tratado Antártico y no lo modifica ni lo enmienda<sup>93</sup>.

En el Protocolo, las partes se comprometieron a la protección global del medio ambiente antártico y de sus ecosistemas dependientes y asociados. En ese sentido, se designó a la Antártida como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia y se establecieron los principios básicos aplicables a las actividades humanas en ese lugar. El artículo 7 prohíbe todas las actividades relacionadas con los recursos minerales, excepto las que tengan fines científicos. Cabe aclarar que, durante los primeros cincuenta años de vigencia del Protocolo, esta disposición no puede ser objeto de modificación o enmienda.

El Protocolo consta de seis anexos. Los primeros cuatro (Evaluación del Impacto sobre el Medio Ambiente, Conservación de la Fauna y Flora Antárticas, Eliminación y Tratamientos de Residuos y Prevención de la Contaminación Marina) fueron adoptados en 1991 junto con el Protocolo. El anexo v, sobre Protección y Gestión de Zonas, fue adoptado por la XVI RCTA en Bonn, República Federal de Alemania, en 1991 y entró en vigor en 2002. El anexo vi, sobre Responsabilidad Derivada de Emergencias Medioambientales, fue adoptado en la XXVIII RCTA en Estocolmo, Suecia, en 2005.

El Protocolo también estableció el Comité para la Protección del Medio Ambiente (CPA) como grupo de expertos para proveer asesoramiento y formular recomendaciones a la RCTA sobre la implementación del Protocolo<sup>94</sup>. El CPA se reúne todos los años en ocasión de la Reunión Consultiva del Tratado Antártico.

### 3.2.3. La Convención para la Conservación de las Focas Antárticas (CCFA)

La Convención fue adoptada el 1 de junio de 1972 y entró en vigor el 11 de marzo de 1978. La CCFA aplica a todas las especies de focas que habitan los mares antárticos. Su objetivo es promover y plasmar los valores de protección, investigación científica y utilización racional de los pinnípedos antárticos.

En ella se reconoce la necesidad de un acuerdo internacional para la conservación efectiva de las poblaciones de focas antárticas. Entre las focas protegidas se encuentran las especies elefante marino, leopardo marino, foca de Weddell, foca cangrejera, foca de Ross y lobo de dos pelos<sup>95</sup>.

### 3.2.4. La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA)

La Conferencia sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) se llevó a cabo en Canbera del 7 al 20 de mayo de 1980 y culminó con la adopción de la Convención homónima.

El objetivo de la CCRVMA es la conservación de las poblaciones de peces, moluscos, crustáceos y todas las demás especies de organismos vivos, incluidas las aves que forman parte del ecosistema marino antártico<sup>96</sup>.

Asimismo establece los principios generales de conservación de los recursos vivos marinos, indicando que se debe prevenir la disminución del tamaño o de la población de cualquier especie recolectada y mantener las relaciones ecológicas entre las poblaciones en cuestión.

La CCRVMA estableció una Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, cuyas funciones se mencionan en el artículo ix, entre las cuales se encuentran la facilitación de las investigaciones y estudios sobre los recursos marinos, la compilación de datos sobre el estado y los cambios de la población de los recursos vivos, la determinación de las necesidades de conservación y la formulación y adopción de medidas para la conservación de los recursos.

### 3.2.5. El Sistema del Tratado Antártico y las Naciones Unidas

El régimen del Sistema Antártico fue negociado y desarrollado por fuera del marco de las Naciones Unidas. El debate actualmente está centrado en si existe la necesidad de negociar un nuevo acuerdo sobre la región antártica que incluya a todos los Estados que participan en la comunidad internacional<sup>97</sup>. Como se ha señalado, el artículo iv del Tratado Antártico congeló los reclamos territoriales realizados por los Estados reclamantes previos a 1959. En ese sentido, será muy difícil negociar un nuevo acuerdo internacional mientras siga vigente el Tratado Antártico.

Entre los principales problemas que plantea la relación entre el STA y las Naciones Unidas pueden ser mencionados: 1) el estatus jurídico de la Antártida, con relación al artículo iv del Tratado Antártico; 2) el estatus jurídico del sector de la Antártida no reclamado por ningún Estado; 3) la membresía agravada para acceder al Tratado Antártico; 4) la distribución de los beneficios económicos; 5) las cuestiones medioambientales, y 6) la resolución de conflictos entre el Tratado Antártico y otros regímenes jurídicos, en especial la CONVEMAR<sup>98</sup>.

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha exhortado a los miembros consultivos del Tratado Antártico a facilitar la participación de la comunidad internacional en las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico en varias resoluciones<sup>99</sup>. Si bien ha habido cambios en el marco de las RCTA, en el sentido de que ahora prevén la participación de Estados no consultivos, todavía existe un cierto déficit democrático en cuanto a la toma de resoluciones con respecto al territorio antártico.

Lo cierto es que, hasta el momento, el Sistema del Tratado Antártico ha demostrado permanecer inmune a los cuestionamientos realizados por la comunidad internacional desde el momento de su creación, y existe gran reticencia por parte de los Estados reclamantes de soberanía sobre la Antártida a acceder a la negociación de un nuevo tratado internacional que no reconozca sus reclamaciones territoriales.

### 3.2.6. El Sistema del Tratado Antártico y la CONVEMAR

El Sistema del Tratado Antártico establece un régimen jurídico no solo para el continente, sino también para los océanos australes. En ese sentido, resulta importante señalar los conflictos que pueden llegar a producirse entre las provisiones contenidas en el Sistema del Tratado Antártico y la CONVEMAR, que regula principalmente los espacios marinos<sup>100</sup>.

La discusión se centra sobre todo en determinar si las normas establecidas por la CONVEMAR pueden ser aplicables a la situación particular de la Antártida. Cabe mencionar que el Tratado Antártico establece en su artículo vi:

Las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a la región situada al sur de los 60° de latitud Sur, incluidas todas las barreras de hielo; pero nada en el presente Tra-

93 Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente, artículo 4.

94 *Ibid.*, artículo 12.

95 Convención para la Conservación de Focas Antárticas, artículo 1.

96 Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, artículo ii. Para un análisis más detallado sobre el funcionamiento de la CCRVMA, ver Mansi, Ariel R., *op. cit.*, pp. 89-107.

97 Chopra, Sudhir, *op. cit.*, p. 1.

98 *Ibid.*, p. 4. Ver también Nascimbene de Dumont, Norma, *op. cit.*, pp. 55-60; Cullen, Domingo, *op. cit.*, pp. 61-67.

99 Resoluciones de la Asamblea General relativas a "Cuestión de la Antártida", entre las que se puede mencionar Resolución A/RES/38/77, Resolución A/RES/39/152 y Resolución A/RES/41/68, entre muchas otras.

100 Rothwell, Donald, "The Law of the Sea and the Antarctic Treaty System: Rougher Seas Ahead for the Southern Ocean", en *The Law of the Sea and Polar Maritime Delimitations and Jurisdictions*, Rothwell, Donald (ed.), Kluwer Law International, La Haya, 2001, p. 113.



tado perjudicará o afectará en modo alguno los derechos o el ejercicio de los derechos de cualquier Estado conforme al Derecho Internacional en lo relativo a la alta mar dentro de esa región.

Ahora bien, mientras que la CONVEMAR recoge muchas de las normas consuetudinarias que existían al momento de la suscripción del Tratado Antártico, lo cierto también es que ha habido un desarrollo progresivo por parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar, como la existencia de una zona económica exclusiva o la extensión del mar territorial a 12 millas marinas. Estas modificaciones entran en conflicto principalmente con la previsión contenida en el artículo IV del Tratado Antártico, que prohíbe la ampliación de los reclamos territoriales sobre la región.

En particular se presentan problemas relativos a lo siguiente: 1) la determinación de las líneas de base en el territorio de la Antártida; 2) la existencia de una zona económica exclusiva; 3) la plataforma continental de la Antártida; 4) la delimitación del océano Austral, y 5) la explotación de recursos en la región antártica<sup>101</sup>.

Lo que sucede aquí es un claro conflicto de fragmentación internacional material entre dos regímenes jurídicos cuasiautónomos que regulan la situación jurídica en un mismo ámbito de aplicación territorial. Será el acuerdo de los Estados cuyos intereses se vean afectados, y la presión que la comunidad internacional pueda efectuar, lo que determinará la solución entre estos dos regímenes.

## CAPÍTULO 24

# RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CURSOS Y RECURSOS HÍDRICOS INTERNACIONALES<sup>1</sup>

Patricia L. Lobato Halajczuk

## 1. Introducción

En el presente capítulo nos referiremos al régimen jurídico internacional de los recursos hídricos. Comenzaremos metodológicamente a partir de los principios y regímenes generales que regulan la conservación y el uso sostenible planetario del agua, como recurso común, vital y universal<sup>2</sup> (conforme lo establece el orden natural<sup>3</sup>), para luego referirnos a los regímenes particulares que determinan derechos especiales, cuando el agua se encuentra contenida geográficamente en cauces o cursos hídricos internacionales compartidos entre Estados o transfronterizos<sup>4</sup>.

## 2. Evolución, desarrollo conceptual y jurisprudencial

Sin perjuicio del logro destacable de la entrada en vigor —el 17 de agosto de 2014— de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos No Navegables de Cursos de Aguas Internacionales (1997)<sup>5</sup> (en adelante la Convención de 1997), podría decirse que, en la actualidad, aún no existe un régimen jurídico internacional único, integral y universal

101 Vigni, Patricia, "The Interaction Between the Antarctic Treat System and the Other Relevant Conventions Applicable to the Antarctic Area: A Practical Approach versus Theoretical Doctrines", en *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, Frowein, Jochem Abraham y Wolfrum, Rüdiger (eds.), Kluwer Law International, La Haya, 2000, pp. 461-642.

1 En nombre de los niños, en especial de mis hijos María Belén e Ignacio Demarchi, y en memoria de mis amigos Mariana García Torres y Ariel González y de mi abuelo Bohdan Tadeo Halajczuk, quienes en vida, como destacados profesores y juristas, lucharon fervientemente por el desarrollo del derecho internacional desde la óptica del desarrollo sostenible, para garantizar el disfrute equitativo de los derechos planetarios de las generaciones presentes y futuras, titulares originarias de aquellos.

2 Se excluye en el presente capítulo el agua de los océanos, pues se encuentra regulada por el derecho internacional del mar, conforme se analiza en los capítulos 27 a 34 de la presente obra y sin perjuicio de la obligación de los Estados ribereños del recurso hídrico de preservar el medio marino (Conf. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Usos No Navegables de Cursos de Aguas Internacionales (1997), artículo 23).

3 En relación con el orden o las leyes de la naturaleza, donde existe, en virtud del principio de causalidad, una disposición por la cual cada cosa ocupa el lugar que le corresponde y cumple con la función que le es propia.

4 El planeta Tierra contiene 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua, únicamente el 2,53 % es dulce. Del agua dulce total, un 68 % está confinada en los glaciares y un 30 % se encuentra en el suelo, almacenada en acuíferos. En la actualidad, más de 7 millones de personas en sesenta países sufren de escasez por la disminución drástica de las precipitaciones y las consecuentes sequías en grandes extensiones del planeta, mientras que, entre las latitudes 30 N y 30 S, se sufren inundaciones como consecuencia de su incremento; en tanto, el agua que existe en el planeta, en virtud de sus ciclos, puede circular o transformar su estado (líquido, sólido o gaseoso), pero nunca modificar su cantidad (ni su calidad), esta nunca cambia, siempre se mantiene constante. Cfr. Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, *The World Water Development Report (WWDR)*, "Agua para todos", UNESCO, Francia, y UNESCO-WWAP, UNESCO/Mundi-Praxis Libros, 2003, p. 10.

5 Suscripta en Nueva York, 21/05/1997.